

1500251-09.2022.8.26.0022

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... indivíduo estaria promovendo o tráfico de entorpecentes no Jardim São Dimas, notadamente em um local bastante conhecido como ponto de tráfico.

A delação mencionava, ainda, as características físicas e as vestimentas do traficante. Deste modo, a equipe diligenciou imediatamente ao local. De fato, quando ainda se aproximavam, os agentes já puderam avistar o réu WESLLEY - o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

2ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo - SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500251-09.2022.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500251-09.2022.8.26.0022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY RIAN DE MELO FONSECA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra WESLLEY RIAN DE MELO FONSECA, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 67/68):

"Segundo as peças do inquérito policial, no dia 31 de março de 2022, às 21h30, na Avenida Orlando Audrai Barros Bueno, 82, Jardim São Dimas, nesta cidade e Comarca de Amparo, WESLLEY RIAN DE MELO FONSECA, qualificado às fls. 14, trazia consigo, para inequívocos fins de comercialização, 18 (dezoito) eppendorfs de cocaína, pesando aproximadamente 33,16g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O acusado foi devidamente notificado (fl. 78) e apresentou defesa preliminar (fls. 83/84). A denúncia foi formalmente recebida em 02 de agosto de 2022 (fls. 87/88). No decorrer da instrução processual, foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público, após analisar o conjunto probatório, entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a

autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação nos termos da peça exordial acusatória.

Por sua vez, em alegações finais, a defesa do acusado requereu a sua absolvição em razão da ilegalidade na abordagem, uma vez que os guardas municipais não possuem competência para exercer serviços designados às outras polícias, de modo que toda a prova colhida nos autos se tornou ilícita. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou a aplicação do "tráfico privilegiado".

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fl. 09), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 10/11), fotografia das drogas (fl. 12) e, especialmente, pelo laudo químico-toxicológico (fls. 70/72).

A autoria é igualmente certa e recai sobre o acusado. Consta dos autos que, na data dos fatos, uma equipe da Guarda Municipal tomou conhecimento de que um determinado indivíduo estaria promovendo o tráfico de entorpecentes no Jardim São Dimas, notadamente em um local bastante conhecido como ponto de tráfico.

A delação mencionava, ainda, as características físicas e as vestimentas do traficante. Deste modo, a equipe diligenciou imediatamente ao local. De fato, quando ainda se aproximavam, os agentes já puderam avistar o réu WESLLEY - o qual preenchia exatamente as características anotadas.

Ocorre que, tão logo o acusado percebeu a movimentação da viatura, empreendeu fuga em direção a uma viela. Os guardas municipais se dividiram e passaram a realizar uma espécie de cerco. Enquanto corria, o acusado dispensou 18 eppendorfs de cocaína pelo caminho.

Por fim, WESLLEY foi finalmente detido e trazia R\$ 130,00 em notas trocadas. Um dos guardas retornou pela rota da fuga e logrou êxito na apreensão dos entorpecentes dispensados. O próprio acusado acabou por admitir à equipe que estava praticando a venda de drogas no local.

Leonardo Campassi Santa Cruz, guarda municipal, prestou depoimento em Juízo e confirmou os fatos. Explicou que foram até o local para a averiguação de uma denúncia envolvendo tráfico de drogas. Já era um lugar conhecido como "ponto de vendas", no Bairro São Dimas. Tão logo chegaram no local, o acusado empreendeu fuga, vindo a ser capturado posteriormente. Na sequência, refez o caminho utilizado na fuga e encontrou as drogas que haviam sido dispensadas pelo réu. Explicou que a delação indicava as características do traficante, as quais corresponderam ao acusado. Além disso, ele veio a confessar a traficância.

Claudio Marcio Rodrigues Simões, também guarda municipal, corroborou integralmente os relatos do seu parceiro de farda. Explicou que deu a volta com a viatura para tentar cercar o acusado, ao passo que o seu parceiro desembarcou para detê-lo a pé.

Por fim, conseguiram efetuar a abordagem na Rua Leonel Mantovani. Ele havia dispensado os 18 pinos de cocaína durante a fuga.

Não há qualquer dúvida acerca da prática do crime pelo acusado. Não há notícias nos autos ou justificativas para explicar um eventual complô dos guardas para prejudicar injustamente o réu. Não é demais lembrar que os depoimentos prestados por agentes policiais podem (e devem) ser utilizados como um lícito meio de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos fáticos. Isso é o que entende a jurisprudência:

"Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (STJ - HC 449657/SP, 5ª T., rel. Ministro Felix Fischer, j. 07.08.2018).

Ademais, o próprio réu veio a confessar formalmente o crime em Juízo. WESLLEY alegou que é dependente químico e que estava devendo dinheiro a traficantes, razão pela qual decidiu vender drogas para pagar sua dívida. Quando os guardas apareceram, tentou fugir e não conseguiu. Explicou que estava vendendo cada porção

por R\$ 10,00, ao passo que a sua dívida era de R\$ 500,00.

A confissão do acusado corrobora os demais elementos de convicção produzidos. Desta maneira, comprovada a conduta delituosa do réu, de rigor sua condenação, nos mesmos termos expostos na denúncia.

A principal tese trabalhada pela defesa técnica diz respeito a uma eventual nulidade das provas em razão da irregularidade da prisão. Isso porque, segundo argumenta, os guardas municipais não possuem permissão legal para a realização de abordagens ou prisões, na medida em que estariam excedendo suas atribuições e invadindo funções próprias das polícias militar e civil.

Não possui razão a defesa. Conforme bem demonstrado, WSLLEY foi encontrado em situação de evidente flagrante: estava em um “ponto de tráfico” e, tão logo avistou uma viatura, saiu correndo e dispensando drogas pelo caminho – deixando patente para qualquer um que estava em situação ilícita.

Não custa lembrar que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.

Sobre a possibilidade do flagrante por parte dos guardas municipais, não há qualquer polêmica na Jurisprudência:

“Apesar das atribuições previstas no art. 144, §8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão” (STJ – AgRg no HC 626577/SP, 5ª T., rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.12.2020).

E ainda:

“A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social” (STJ – HC 129932/SP, 5ª T., rel. Arnaldo Esteves Lima, j. 15.12.2009).

É certo que a defesa mencionou um julgado recente proveniente da 6ª Turma do Egrégio STJ versando sobre a delimitação das funções exercidas por guardas municipais. Entretanto, este Juízo entende que a situação combatida no mencionado acórdão é distinta daquela verificada nos presentes autos – na medida em que, no caso ora apreciado, a situação de flagrante era bastante clara.

Seja como for, é bom ressaltar que o entendimento adotado no julgado mencionado pela defesa não parece ser tão unânime e pacífico na Jurisprudência dos Tribunais pátrios – nem mesmo do próprio Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa” (STJ – AgRg no HC 667.413/SP, 6ª T., rel. Ministra Laurita Vaz, j. 01.06.2021).

“HABEAS CORPUS [...]. Sobre o tema, inegável reconhecer a legalidade do exercício do policiamento preventivo pela Guarda Municipal, seja com competência própria (prevista em decretos ou leis municipais), seja em auxílio à Polícia Militar. Portanto, resta claro que os guardas municipais, no exercício de suas atribuições legais e no limite delas, podem dar ordens que, se não cumpridas, podem dar ensejo ao crime de resistência por parte do agente que as descumpriu” (STJ – HC 712710/SP, 5ª T., rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 15.02.2022).

E ainda:

“A jurisprudência desta eg. Corte Superior, há muito, firmou posicionamento no sentido de que, inclusive para abordagens em via pública, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º, da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP” (STJ – AgRg no HC 657974/SP, 5ª T., rel. Ministro Felix Fischer, j. 01.06.2021).

Por fim, analisando as circunstâncias acerca da aplicação da pena, verifico que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da figura privilegiada prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – conforme reconhecido pela própria representante do Parquet.

Com efeito, o réu não possui condenação criminal (conforme fls. 37/38) e não houve demonstração firme de que se dedicava frequentemente à prática de crimes. Os guardas municipais ouvidos declararam que não conheciam o acusado anteriormente. Tais elementos demonstram, ao menos em aparência, que a traficância foi algo pontual na vida do réu. Quanto à diminuição, considerando o número pequeno de porções apreendidas, a pena poderá ser diminuída no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu efetivamente praticou o delito, nos termos descritos na denúncia. Isso decorre a partir da análise e valoração dos diversos elementos de convicção carreados aos autos, especialmente pelos depoimentos dos guardas municipais que participaram da ocorrência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR WESLEY RIAN DE MELO FONSECA como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em razão disso, passo a dosar as penas, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui Maus antecedentes, tecnicamente. Não existem dados suficientes para se aferir sua personalidade. O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou a confirmação exata do tempo em que se comercializavam as drogas.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Presentes duas circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, vez que o acusado era menor de 21 anos na época dos fatos (inciso I) e optou por confessar o crime em Juízo (inciso III, “d”). Porém, deixo de atenuar a reprimenda, já que esta já se encontra no mínimo legal – em conformidade com a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Verifico, no presente caso, a hipótese de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Levando em consideração a fundamentação exposta no corpo da sentença, diminuo a pena em 2/3 (dois terços).

Tendo em vista a inexistência de causas de aumento, torno definitiva a pena do acusado em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Em face do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, e levando-se em consideração o atual entendimento dos Tribunais Superiores, o réu poderá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade, anteriormente dosada, em regime aberto.

Haja vista os termos da Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, bem como o entendimento firmado pelo STF nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, é cabível a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, nos casos em que for aplicado o privilégio do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

No caso dos autos, verifico que o réu preenche todos os requisitos alinhados no artigo 44 do Código Penal, de modo que a substituição da pena se revela suficiente à repressão do delito.

Assim sendo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo a ser destinada a alguma instituição assistencial, a ser escolhida pelo d. Juízo da execução, por se configurar na

melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, como forma de que o sentenciado compreenda o caráter ilícito de sua conduta.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Quanto ao numerário apreendido na ocorrência (R\$ 130,00), tendo em vista ser fruto do tráfico, determino seu perdimento em favor da União, devendo a serventia providenciar a necessária transferência à SENAD após o trânsito em julgado da condenação (fl. 61).

Expeça-se a devida certidão de honorários ao Patrono nomeado pelo convênio DPE/OAB, na proporção dos serviços prestados (fl. 34).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Expeça-se a guia de execução do réu.

2) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do contido no artigo 15, III, da Constituição Federal.

3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

4) Oficie-se à SENAD, nos termos do artigo 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da Lei.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Amparo, 20 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA